

1500041-73.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Eduardo confessou a prática do tráfico e aduziu que vendia entorpecentes desde dezembro do ano passado, em virtude de dificuldades financeiras. Afirmou que é analfabeto e, por isso, pressionava a acusada a encaminhar mensagens a terceiros sobre o comércio espúrio. Embora ela soubesse de seu envolvimento no tráfico, não tinha qualquer participação na atividade ilícita nem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500041-73.2022.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004407/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22292410 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 100/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2004407 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO JOAO DO NASCIMENTO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

EDUARDO JOÃO DO NASCIMENTO e TATIANA RIBEIRO BOROSKI estão sendo processados como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, combinados com os artigos 29 e 69 do Código Penal.

Notificados (fls. 289 e 291), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 342/346).

A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2022 (fls. 362/363) e os acusados foram citados (fls. 403/405).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus (fls. 409/410).

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição de Tatiana e a de Eduardo em relação ao crime de associação. Subsidiariamente, postulou a aplicação da pena mínima legalmente cominada e das benesses legais.

O julgamento foi convertido em diligência para que as partes se manifestassem sobre os documentos juntados (fls. 415, 420 e 424).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, não se observa o cerceamento suscitado pela defesa (fls. 424), vez que o patrono dos acusados teve oportunidade de analisar e se manifestar sobre os documentos juntados aos autos (fls. 415 e 424) e nada requereu em complementação.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 10/19), boletim de ocorrência (fls. 20/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), fotografias (fls. 74/76), informações (fls. 78/82 e 296/341), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 196/201), laudos periciais (fls. 202/205 e 206/216) e pela prova oral.

Interrogado em juízo, Eduardo confessou a prática do tráfico e aduziu que vendia entorpecentes desde dezembro do ano passado, em virtude de dificuldades financeiras. Afirmou que é analfabeto e, por isso, pressionava a acusada a encaminhar mensagens a terceiros sobre o comércio espúrio. Embora ela soubesse de seu envolvimento no tráfico, não tinha qualquer participação na atividade ilícita nem conhecimento de que havia droga armazenada na residência.

Tatiana negou a perpetração dos crimes e disse que nunca se envolveu com o uso ou tráfico de drogas. Afirmou que Eduardo é analfabeto e, por isso, fazia anotações para ele e encaminhava as mensagens escritas. Também enviou mensagens de áudio porque temia ser expulsa de casa, caso não o fizesse. Iniciou mencionadas anotações cerca de um mês antes de serem presos. Morava com o corréu há aproximadamente dois meses, desde que ele deixou o cárcere, contudo não sabe há quanto tempo ele traficava.

O policial civil Filipe relatou que foram realizadas diligências destinadas a apurar informações sobre o tráfico na rodoviária e adjacências que indicavam o gerenciador como sendo "Du"/"Duzinho". Foi efetivado monitoramento ao acusado e realizada filmagem na qual ele aparece em transação indicativa de venda de entorpecente. Na data do cumprimento do mandado expedido em desfavor do acusado, estavam no imóvel os réus e o filho de Tatiana. Eduardo colaborou com a equipe e mostrou que os entorpecentes estavam dentro de um guarda-roupa - em consonância com as denúncias previamente recebidas -, onde foram localizadas porções de crack e um pedaço maior de maconha. Na sala foi encontrado um caderno com anotações aparentando ser de controle do comércio espúrio. O réu admitiu que praticava o tráfico e afirmou que a acusada não participava da atividade, malgrado ela soubesse que ele o fazia e escrevesse as anotações porque é analfabeto. A despeito de não ter visualizado a ré durante as campanhas, ao analisar o conteúdo do celular dela percebeu que a sua atuação excedia o simples auxílio ao acusado com leitura e escrita, vez que havia arquivos de áudio gravados por ela indicando seu envolvimento ativo no comércio espúrio, intermediando conversas entre terceiros e seu marido.

No mesmo sentido, em linhas gerais, as declarações do policial civil Bruno.

Pois bem.

O réu Eduardo confessou parcialmente a prática dos delitos, pois admitiu o tráfico, mas tentou afastar a responsabilidade de Tatiana.

A confissão do acusado foi corroborada pelos demais elementos de prova, em especial o relatório de informações dos dados extraídos de seu celular (fls. 296/341) e de fls. 09/10 das peças sigilosas. Vislumbra-se das inúmeras mensagens de texto e de áudio intensa atividade de Eduardo no comércio espúrio, comprando entorpecentes de fornecedores “maiores”, inclusive do litoral paulista, e os vendendo a traficantes “menores”. Ademais, Eduardo foi filmado em transação de venda de droga durante campanha da polícia civil (link de fl. 408).

E não merece acolhimento a pueril alegação dos acusados de que Tatiana não participava voluntariamente da atividade ilícita do companheiro e apenas o fazia mediante coação, pois claramente ventiladas para tentar afastar a responsabilidade penal da ré.

O relatório de informações acostado às fls. 296/341 demonstra que ela participava ativamente com Eduardo dos negócios espúrios. Merece destaque o conteúdo de fls. 302, 306, 307, 311, 314, 315, 328 e 335/336, do qual se observa que Tatiana era bem conhecida dos traficantes, que a chamavam de “cunhada”, e, além de intermediar as negociações deles com seu companheiro e encaminhar mensagens escritas em nome dele, ela também gerenciava a parte financeira do tráfico exercido pelo casal, responsabilizando-se pelo pagamento de fornecedores por meio de PIX e cobrando dívidas.

Vale transcrever algumas conversas:

Fls. 314/315 - entre Tatiana e o interlocutor “Jai” (este, como é possível concluir da conversa entre ele e Eduardo de fls. 313/314, também recebe do casal entorpecente em porções grandes e os fraciona individualmente para venda):

- “O 'JAI', TRÁS DOIS PINO FAZENDO O FAVOR...”;
- “O 'JAI', PEDE PRO 'VEINHO' DESCE DAQUI CINCO MINUTO, TÁ, ENTÃO AÍ JÁ DA TEMPO DE VOCÊ FAZÊ, AÍ VOCÊ JÁ DEIXA PRONTO, ELE JÁ PEGA E VEM, TÁ?”;
- “O 'JAI', CÊ TIRA FOTO DO QUE VOCÊ VAI MANDA PRA MIM E FOTO DE QUANTO TÁ FICANDO AÍ, TÁ, FAZENDO O FAVOR”;
- “ISSO 'JAI', AGORA CÊ FAZ OUTRO DE CINCO...”
- “AÍ DEPOIS CÊ SABE O QUE CÊ FAZ, CÊ PEGA E PESA O QUE VAI FICA AÍ, SÓ PRA GENTE VÊ...x.

Fls. 328 - entre Tatiana e Eduardo, na qual ela informa ao companheiro sobre uma dívida de “Titi” que ela cobrara no dia anterior, sem sucesso (print de fl. 329): “O 'EDUARDO', DEIXA EU FALA PRA VOCÊ, NO SEU TELEFONE AÍ TEM O CONTATO DO 'TITI', OU SENÃO EU VO PASSA E VOCÊ PEGA E FALA COM ELE, TÁ, PORQUE AQUELE DIA EU FALEI COM ELE, ONTEM EU FALEI COM ELE E ELE VEIO FALANDO QUE TÁ DOENTE, QUE NÃO SEI O QUE, ENFIM, JÁ VAI FAZE MAIS DE UMA SEMANA QUE ELE TÁ COM, COM A 'SITUAÇÃO LÁ, TANTO A AMARELA COMO A BRANCA', ENTENDEU, 'E ATÉ AGORA NÃO CHEGO NADA', ENTÃO ASSIM, VOCÊ FALA COM ELE, MANDA UM ÁUDIO PRA ELE”.

De outro lado, os policiais civis foram uníssomos em suas oitivas quanto às circunstâncias da campanha e do cumprimento do mandado de busca e apreensão, que restou frutífero com a apreensão de dinheiro, drogas e outros objetos.

A finalidade de entrega a terceiro restou comprovada pela confissão de Eduardo, pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas no lar dos acusados, além da localização de faca com resquício de maconha (fls. 202/205), de caderno com

anotações de tráfico e de dinheiro sem origem lícita comprovada, somados às diversas mensagens extraídas do celular do réu e do conteúdo da interceptação telefônica (fls. 09/10 das peças sigilosas).

Como acima esposado, também restou inconteste a associação de forma estável e permanente entre os réus para perpetração do tráfico, atuando conjuntamente em diversas negociações de drogas e as armazenando em sua casa para posterior entrega a terceiros.

Nesse contexto, suficientemente comprovada a prática, pelos acusados, dos crimes narrados da denúncia, de rigor a procedência da ação penal.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, observo pela certidão de fls. 267/273 c.c. fls. 257/259 que Eduardo possui maus antecedentes (Processos nº 262/2000, 189/2003 e 0009471-95.2009.8.26.0302). A pena-base merece aumento, ainda, em virtude da alta potencialidade lesiva de parte dos entorpecentes armazenados e comercializados pelos réus - crack - substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo suas penas-base acima do mínimo legal em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa para o delito de tráfico e 4 anos de reclusão e 933 dias-multa para a associação.

Em relação a Tatiana, considerando a alta potencialidade lesiva de parte dos entorpecentes apreendidos - crack - substância altamente nociva e viciante, majoro suas penas-base de 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (artigo 33, Lei nº 11.343/06) e 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa (artigo 35 da mesma norma).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão no tocante a prática do tráfico por Eduardo e a agravante da reincidência (fls. 267/273 - Processo nº 0012120-96.2010.8.26.0302). Para ambos, incide a agravante descrita no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos").

Assim, para Eduardo, em atenção ao disposto no artigo 67, CP, e ao fato de que sua reincidência é específica, aumento a reprimenda do delito de tráfico de $\frac{1}{4}$ para 8 anos e 4 meses de reclusão e 781 dias-multa, e majoro a pena da associação de $\frac{1}{3}$ para 5 anos e 4 meses de reclusão e 1.244 dias-multa. Para Tatiana, aumento as reprimendas de $\frac{1}{6}$ para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa (tráfico) e 4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa (associação).

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da comprovação de que os réus se dedicavam à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes em associação. Nesse sentido:

Apelação 990081551276
Relator(a): André Carlos de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 29/05/2009

Data de registro: 04/08/2009

Ementa: TRÁFICO DE DROGAS. Natureza, Variedade e Quantidade da Droga.

Circunstâncias da Prisão. Condições econômicas das agentes. É intuitivo, pela natureza e quantidade da droga (maconha, 16,94 kg), sua disposição (distribuídas em 12 tijolos), ocultação (malas de viagem), que se destinava ela ao tráfico ilícito e clandestino. PROVA. Policiais Militares. É sem sentido desprestigiar depoimentos de policiais militares, os quais, até a abordagem, desconheciam completamente o recorrente e motivo algum, particular e infundado, possuíam para falsamente incriminá-las. Credenciados pelo Estado, crítico seria a negativa de prestarem versão sobre condutas profissionais que realizaram. Associação para o tráfico. Perfeitamente possível o concurso material do crime de tráfico, do artigo 33 da Lei de drogas, com a associação do artigo 35 da mesma Lei, em especial porque provado, no particular, a divisão de tarefas, submissão a tarefas adrede atribuídas a uma e outra apelante, com recebimento de paga pela disposição em traficar. Tráfico e Associação. Redução de pena com fundamento no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Impossibilidade. O fato de se reconhecer o crime de associação refuta, só por si, a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. É que o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 nada mais do que o crime de bando ou quadrilha dessa Lei, induzindo à conclusão de que não se justifica a benesse da redução da pena.

Presente o concurso material de crimes, as penas deverão ser somadas, perfazendo 13 anos e 8 meses de reclusão e 2.076 dias-multa para Eduardo e 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.632 dias-multa para Tatiana.

Considerando as penas aplicadas, os motivos esposados na primeira fase e os maus antecedentes e reincidência de Eduardo, fixo para ambos o regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas

Arbitro o valor do dia-multa no patamar mínimo para ambos os acusados, pois ausentes elementos que demonstrem serem eles capazes de arcar com valor maior.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,

respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF)”(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR, como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, combinados com o artigo 69 do Código Penal, EDUARDO JOÃO DO NASCIMENTO à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.076 dias-multa, no mínimo legal, e TATIANA RIBEIRO BOROSKI à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, no mínimo legal.

Os réus não poderão apelar em liberdade, pois remanescem os requisitos que ensejaram a decretação de suas custódias cautelares (fls. 128/132), notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Recomendem-se, pois, na prisão em que se encontram.

Por fim, decreto o perdimento dos objetos e valores apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA